

1500379-84.2022.8.26.0618

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: João Carlos Germano

Comarca: Taubaté

Foro: Foro de Taubaté

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andrew Henrique Aguilera Diaz

Réu Preso

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Andrew Henrique Aguilera Diaz foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 22 de março de 2022, por volta das 17h30min, na Rua Jean Benedito Abud. Sítio Santo Antônio, B. Água ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Taubaté

Foro de Taubaté

3ª Vara Criminal

Praça Monsenhor Silva Barros - s/nº, Fórum Criminal

CEP: 12020-070 - Taubaté - SP

Telefone: (12) 2124-9113 - E-mail: taubate3cr@tjsp.jus.br

1500379-84.2022.8.26.0618 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500379-84.2022.8.26.0618

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Andrew Henrique Aguilera Diaz

Réu Preso

Juiz de Direito: João Carlos Germano

Vistos.

Andrew Henrique Aguilera Diaz foi denunciado pelo Ministério Público porque, no dia 22 de março de 2022, por volta das 17h30min, na Rua Jean Benedito Abud. Sítio Santo Antônio, B. Água Quente, nesta cidade e comarca de Taubaté, agindo sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, guardava para fins de venda

ou entrega a terceiros consumidores, 88 pinos de cocaína, com massa líquida de 44,1 gramas.

Segundo apurado pela acusação, na data dos fatos, durante patrulhamento de rotina, policiais militares receberam informações de que um indivíduo trajando camisa listrada de cor azul estava praticando o tráfico de drogas, repassando o endereço de onde se encontrava.

Os policiais se deslocaram até o local declinado e abordaram o réu sendo encontrada em sua posse a quantia de R\$ 66,00 e um telefone celular.

Indagado a respeito da denúncia anônima, o denunciado confessou que estava vendendo drogas, esclarecendo que aceitava PIX como forma de pagamento, sendo encontrados 7 pinos de cocaína entre a grama e o paralelepípedo da guia e outros 81 pinos próximo ao escadão.

Busca, assim, a condenação do réu como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

A denúncia foi recebida às fls. 60/62.

Citado (fls. 81), o réu apresentou resposta escrita à acusação às fls. 85.

Designou-se audiência, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas Frank Jackson dos Santos, Wesley de Almeida Santos e Elias Rodrigues e procedeu-se ao interrogatório do réu, colhendo-se alegações finais do Ministério Público e da Defesa.

O Ministério Público postulou a procedência parcial do pedido, alegando que a autoria e a materialidade do delito foram parcialmente comprovadas pelas provas existentes nos autos. Ouvidos em juízo, os policiais narraram a abordagem e a apreensão das drogas, próximas ao réu. Interrogado, o réu confessou a mercancia ilícita, justificando que estava com dificuldades financeiras. Inclusive, citou que já havia vendido 3 pinos na ocasião e negou a propriedade da sacola apreendida. Dessa forma, pleiteou a condenação do réu, nos termos da denúncia, pelos 7 pinos apreendidos e os 3 já vendidos por ele. Requereu o afastamento dos 81 pinos localizados posteriormente, uma vez que estavam distantes do réu e, conforme informado pelo próprio, não eram de sua propriedade, destacando que não há comprovação contrária. Defendeu a fixação da pena-base no mínimo legal, pois, embora reincidente, o réu confessou a prática delitiva e colaborou com a investigação policial. Manifestou ser inviável a aplicação do redutor em razão da reincidência. No tocante ao regime, pediu que seja aplicado o fechado. Por fim, solicitou o perdimento do numerário em favor da União.

A Defesa, por sua vez, manifestou-se apenas acerca da fixação da pena, em razão da confissão do réu. Pleiteou que a pena-base seja fixada em patamar mínimo, diante das circunstâncias favoráveis. Ressaltou que o conjunto probatório não possui nada a indicar personalidade voltada a prática delitiva. Ademais, em eventual aplicação da agravante da reincidência, requereu a compensação pela atenuante da confissão, oferecida desde a fase policial. Solicitou que seja fixado regime diverso do fechado e facultado eventual apelo em liberdade.

É o relatório.

Decido.

Cuida-se de ação penal pública incondicionada, por meio da qual o Ministério Público requereu a condenação do réu como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Não há questões preliminares a se enfrentar. As condições da ação estão presentes, assim como os pressupostos processuais, o que rende ensejo à apreciação do mérito.

É o caso de acolhimento do pedido condenatório.

A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls.1), boletim de ocorrência (fls.5/7), termo de depoimento (fls. 2/3), termo de interrogatório (fls. 4), auto de qualificação, vida pregressa e BIC (fls. 10), auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), laudo pericial preliminar (fls. 20/23), laudo definitivo (fls. 64/66) BOPM (fls. 68/71) e pelos depoimentos colhidos em juízo.

Com relação à autoria, melhor sorte não assiste o acusado, em razão da robusta prova atribuindo a ele a prática do crime de tráfico de drogas.

A testemunha Wesley de Almeida Santos, ouvida em juízo, relatou que receberam uma denúncia anônima com as características do réu, notadamente que trajava uma blusa listrada. No local, fizeram sua abordagem e ele confessou que estaria vendendo drogas. Nada de ilícito em sua posse, apenas dinheiro e um celular. Afirmou que o acusado indicou onde estavam os entorpecentes, em uma parte da guia, distante alguns metros. Foram localizados 7 pinos de cocaína. Havia várias pessoas na via pública, que foram dispensadas na ocasião. Posteriormente, em outra diligência, em um escadão distante 20 metros, encontraram o restante das drogas, escondidas em um matagal. Afirmou que não conhecia o réu. Asseverou não terem visualizado atos de mercancia. Questionado, disse haver dois comércios próximos e em funcionamento na oportunidade.

A testemunha Franck Jackson dos Santos, ouvida em juízo, informou que receberam uma denúncia de tráfico no endereço dos fatos. No local, identificaram o réu como sendo o indivíduo mencionado, junto de outras pessoas. Em abordagem, nada de ilícito foi encontrado em posse deles. Com o réu, foram localizados um celular e dinheiro. Indagado, ele confessou a venda de drogas e indicou o seu local de armazenamento. Em uma parte da guia, a 5 metros dele, encontraram 7 pinos de cocaína. Em vistoria no escadão próximo, foi localizada uma sacola contendo outros 81 pinos. Sobre essa segunda quantidade, o réu afirmou não ser de sua propriedade. Alegou que não conhecia o réu.

A testemunha Elias Rodrigues, ouvida em juízo, informou que soube da prisão do réu posterior ao dia dos fatos. Afirmou que não teve contato com ele no dia apurado. Mencionou que ele trabalha com formatação de computadores e celulares. Não tem loja física.

O réu Andrew Henrique Aguilera Diaz, interrogado em juízo, asseverou que tem conhecimento da acusação e afirmou que é verdadeira. Narrou que saiu da casa de Elias, por volta das 15 horas, e, em razão de dificuldades financeiras, optou pela traficância. Trabalha com manutenção de computadores e celulares e como pianista. Informou que só tinha 7 pinos e não sabia da outra quantidade apreendida. Teve conhecimento da sacola apreendida na Delegacia. Estava começando as vendas, sendo esse seu primeiro dia. Possuía R\$ 60,00, provenientes da venda de 3 pinos. Usuário de drogas desde os 12 anos. Negou conhecer os policiais. Destacou não ser portador de maus antecedentes. Disse ser solteiro e não tem filhos.

Bem provadas a autoria e a materialidade.

Dispõe o artigo 33, caput, da Lei de Drogas:

"Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que

gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:"

Observe-se que a conduta do réu se enquadra em diversos verbos do núcleo do tipo, notadamente vender e trazer consigo drogas, resultando, assim, configurada a tipificação do crime em comento.

Anoto que o réu foi preso em flagrante quando tinha sob a sua guarda 7 pinos contendo cocaína.

Nesse sentido foi o depoimento dos policiais que se encarregaram da prisão, dando conta da forma como o delito ocorreu, ressaltando que o réu confirmou que a droga era sua e que estava no local vendendo drogas.

Soma-se a isso a confissão do réu, ao confirmar que realmente estava com a droga em seu poder e que estava no local vendendo drogas.

Dessa forma, não resulta qualquer dúvida acerca do fato cometido pelo réu, devendo ser responsabilizado pela prática delitiva.

Quanto ao restante da droga encontrada, não pode ser imputada ao réu. Com efeito, foi ela encontrada longe do local onde estava o réu, e havia próximo do local dois comércios com diversas pessoas que o frequentavam, sendo que qualquer um poderia ser o dono dos referidos entorpecentes. Ademais, os policiais não visualizaram o réu mexendo no local onde a droga se encontrava.

Nada obstante, impõe-se o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea "d".

O réu era, na data dos fatos imputável. Tinha plena consciência da ilicitude do ato praticado e podia determinar-se de forma diversa, preferindo, porém, o crime. Não concorrem causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade.

A prova é certa, segura e aponta para o cometimento do crime pelo réu, devendo ser responsabilizado.

Na primeira fase impende observar a regra do artigo 42, da Lei 11.343/2006, pelo qual preponderam sobre o artigo 59 a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente.

A despeito da natureza da droga, de grande poder vulnerante, observo que a quantidade de que dispunha não pesa contra o réu, podendo ser considerada dentro da normalidade dos casos atinentes ao tráfico de drogas.

Quanto à personalidade, nada há de relevante.

No que respeita à culpabilidade o que se vê é natural à espécie.

Não ostenta o réu maus antecedentes, porém, tem uma condenação com trânsito em julgado que será aferida no momento oportuno.

Acerca da conduta social do réu não há elementos para que se proceda à sua valoração.

Quanto aos motivos do crime e as circunstâncias, nada há de relevante.

O sujeito passivo do tráfico de drogas é a coletividade, titular do bem jurídico saúde pública, não havendo, então, falar-se em comportamento da vítima.

Assim, ausentes circunstâncias judiciais, fixa-se a pena-base em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na fase intermediária, reconheço a atenuante da confissão. Reconheço, outrossim, a agravante da reincidência, como se infere do processo número 292-18.2016, desta 3.^a Vara Criminal.

Entendo, segundo pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, que a atenuante da confissão deve ser compensada com a agravante da reincidência. Isso porque em recente julgamento resultou definido pela Terceira Sessão da Corte que "A melhor hermenêutica a ser implementada, até mesmo para se evitar descompasso e afronta à proporcionalidade, deverá ser aquela voltada à possibilidade de se compensar a confissão com o gênero reincidência, irradiando seus efeitos para ambas espécies (genérica e específica), ressalvados os casos de multirreincidência" (HC 365.963, relator Félix Fisher, j. 11.10.2017).

Assim, compenso uma pela outra, mantendo-se a pena no patamar de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de diminuição ou de aumento, sendo a pena fixada definitivamente em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento será o fechado.

Trata-se de condenação pelo cometimento do delito de tráfico ilícito de drogas, crime que denota conduta absolutamente perniciosa à sociedade, sobretudo por contribuir com a disseminação da substância ilícita entre a população, fato que, por alcançar patamares insuportáveis, coloca em risco, inclusive, a tranquilidade social e a ordem pública, mormente por ser causa mediata de vários outros delitos, notadamente aqueles de natureza patrimonial. Além disso, o tráfico é equiparado a crimes hediondos e merece, desse modo, tratamento mais severo, sendo que a gravidade da conduta também exige maior rigor por parte do Estado, cabendo ser ressaltado que o réu comercializava cocaína, droga de grande poder viciante.

Nada obstante, o réu é reincidente, reforçando a necessidade da fixação do regime mais rigoroso.

Nos termos do artigo 49, §1.º, do Código Penal, o valor do dia multa será de 1/30 avos do salário mínimo praticado à época do delito, pois ausentes elementos para aferição da capacidade financeira do réu, devendo ser atualizado pelos índices de correção monetária da Tabela Prática do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo desde aquela data até o efetivo pagamento.

Incabível a substituição de pena, pois a medida seria insuficiente e ineficaz à reprovação do agente e à repreensão do delito. Ademais, levando-se em conta, mais uma vez, a gravidade in concreto do crime, insuficiente seria sua aplicação, com fundamento no artigo 44, inciso III, do Código Penal.

Incabível, outrossim, a suspensão da pena prevista no artigo 77, em razão da reprovabilidade e da perniciosidade da conduta da traficância, bem como por afrontar o espírito da Lei 11.343/06, que em seu artigo 44, veda a concessão de sursis.

Anoto, ainda, que a despeito da Resolução n 5, do Senado Federal, que suspendeu a expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", presente no §4.º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, a conversão e o sursis não se fazem adequados à prevenção e repressão do crime em espécie, pois, como já se decidiu, "os efeitos nocivos do crime de tráfico de drogas, que acarretam profundas feridas na sociedade atual, revelam a postura indiferente adotada pelo agente com reação à saúde

pública, o bem estar social, e as nefastas consequências de seus atos, o que vai de encontro com o requisito previsto pelo inciso III, do artigo 44, do Código Penal, qual seja, 'os motivos e as circunstâncias do crime indicarem que essa substituição seja suficiente' (TJSP, apelação 0026205.40.2008.8.26.0405).

Deixo de fixar indenização mínima prevista no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pois inexistente pedido nos autos, fato que inviabiliza o contraditório e a ampla defesa, bem como se afasta do princípio da congruência.

Mantenho a prisão cautelar, recomendando-se o réu naquela em que se encontra.

É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal que inexistente ilegalidade em vedar ao condenado recorrer em liberdade quando esteve preso cautelarmente durante toda instrução criminal, desde que permaneçam os motivos dessa segregação (STF - HC n. 89824/MS - 1ª T. - unânime - Min. Carlos Ayres Britto - DJe 28/8/2008; STF - HC n. 114536/MG - 2ª T. - unânime - Rel. Min. Ricardo Lewandowski - DJe 4/12/2012; STJ - HC n. 222002/RJ - 5ª T. - unânime - Rel. Min. Laurita Vaz - DJe 11/10/2013).

No caso o réu permaneceu preso cautelarmente durante todo o processo. A infração penal praticada pelo réu é grave e o retorno ao convívio social, neste momento, é inoportuno. Assim, para que a ordem pública permaneça acautelada, é necessária a manutenção da prisão do acusado.

O tráfico é crime de enorme gravidade, nefasto, que dissemina as drogas e deturpa a sociedade, destruindo seres humanos e lares e que ampara todo o mundo da criminalidade.

Nesse contexto, ainda persistem os fundamentos fáticos e jurídicos que ensejaram a segregação cautelar, agora mantida com base em um juízo de certeza da culpa.

Não se olvida, ainda, que se trata de réu reincidente, o que denota que a reprimenda sofrida anteriormente não foi capaz de dissuadi-lo de perpetrar novos delitos, sendo necessária a manutenção de sua prisão.

Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do artigo 312 e seguintes do Código de Processo Penal, mantém-se a prisão do réu (artigo 387, parágrafo primeiro, do Código de Processo Penal), negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

Diante de tal quadro, verificada a necessidade da manutenção da custódia cautelar, resulta cumprido o disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Não há dados suficientes para realização da detração da pena, razão pela qual deixo de cumprir o disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, cabendo ao juízo da execução, que detém as informações necessárias, analisar oportunamente eventual direito do réu por conta do período que este permanece preso cautelarmente, consoante determina o artigo 66, inciso III, alíneas "b" e "c". Nesse sentido: (HC 169.072/SP, relator Ministro Og Fernandes - 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, julgado em 10.6.2010).

Declaro o perdimento dos valores apreendidos em favor da União Federal.

Com relação ao dinheiro, não foi comprovado que realmente advinha de lícito labor, impondo-se o perdimento.

Registre-se que seriam fatos de prova relativamente facilitada. Prova documental, no caso concreto, seria a única hábil à comprovação das alegações, mas não veio

para os autos.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, de acordo com o artigo 804, do Código de Processo Penal.

Posto isso, acolho o pedido formulado na denúncia para o fim de condenar o réu Andrew Henrique Aguilera Diaz à pena de 5 anos de reclusão e 500 dias-multa, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, com início de cumprimento de pena no regime fechado, recomendando-o à prisão em que se encontra, negando ao réu o direito de recorrer em liberdade, condenando-o, outrossim, ao pagamento das custas no importe de 100 UFESPs, nos termos do artigo 4.º, § 9.º, alínea "a", da Lei estadual 11.608/03.

Após o trânsito em julgado deverá a Serventia levar a efeito as seguintes providências:

- a) intimar o réu para proceder ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686, do Código de Processo Penal, assim como ao pagamento da taxa judiciária;
- b) oficiar ao TRE para cumprimento do disposto no artigo 15, inciso III, da Constituição Federal;
- c) oficiar ao IIRGD comunicando a condenação do réu;
- d) expedir guia de execução penal.

R.P.I.

Taubaté, 20 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA